NOTE D'INFORMATION

relative à la demande d'arbitrage des investisseurs chinois contre l'Ukraine

1. Informations générales.

Arbitrage : CPA (Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Pays-Bas), affaire *Wang and others v. Ukraine* (n° 2021-22).

Demandeurs : 6 ressortissants de la République populaire de Chine (RPC), qui détenaient au total 76 % des actions de la JSC « Motor Sich » (ci-après « MS »), à savoir : Li Fengzhou, Liu Yanying, Zheng Zhinlin, Cui Changshun, ainsi que Wang Jing et Du Tao (propriétaires effectifs de Skyrizon Aircraft Holdings Limited).

Défendeur : L'Ukraine.

Fondement juridique : Violation par l'Ukraine de l'Accord conclu avec le gouvernement de la RPC sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements en date du 31 octobre 1992.

Les Demandeurs soutiennent que l'Ukraine a procédé à une expropriation illégale de leurs investissements et a manqué à ses obligations relatives au traitement juste et équitable.

L'Ukraine les a privés de leurs droits de propriété sur les actions de MS au moyen d'actes concertés et coordonnés :

- Le Comité antimonopole d'Ukraine (ci-après « AMKU ») a, de manière répétée et sans fondement valable, refusé ou fait traîner en longueur la délivrance de l'autorisation de concentration d'actions ;
- Le Service de sécurité de l'Ukraine (ci-après « SBU ») et le Bureau du Procureur général (ci-après « OGP ») ont exercé des pressions dans le cadre de poursuites pénales (perquisitions, interrogatoires) ;
- Les juridictions ont rendu de multiples ordonnances de saisie des actions (2017, 2018, 2020, 2021), privant les Demandeurs du droit de vote et de la possibilité de convoquer les assemblées d'actionnaires ;
- Le Président et le Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine (ci-après « RNBO ») ont imposé des sanctions personnelles contre les Demandeurs ;
- Dans le cadre de la procédure pénale, les actions ainsi que l'ensemble du patrimoine de MS ont été placés sous saisie pénale conservatoire et remis en gestion à l'Agence nationale pour le recouvrement et la gestion des avoirs (ci-après « ARMA »).

Étapes de la procédure :

- 4 septembre 2020 : Les Demandeurs ont adressé au ministère de la Justice une notification de différend relatif aux investissements (règlement amiable préalable à l'arbitrage). Montant des prétentions : 3,5 milliards USD.
- 5 décembre 2020 : Les Demandeurs ont déposé la Requête d'arbitrage (Notice of Arbitration), déclenchant formellement la procédure arbitrale. Montant des prétentions : 3,6 milliards USD.
- 15 novembre 2021 : Les Demandeurs ont déposé leur Mémoire en demande (Statement of Claim), exposant de manière détaillée le bien-fondé de leurs demandes. Montant des prétentions : 4,59 milliards USD (réévalué à la suite d'une expertise économique des investissements perdus).

Prétentions indemnitaires :

En raison de l'expropriation par l'Ukraine des actions de MS, les Demandeurs réclament la réparation intégrale des préjudices subis à hauteur de 4,59 milliards USD, se décomposant comme suit :

- 100 millions USD : investissements directs de Skyrizon ;
- 1,46 milliard USD : indemnisation au titre de la perte des actions de la JSC « Motor Sich » ;
- 3,03 milliards USD : pertes subies par Wang Jing, actionnaire de Xinwei (voir ci-après), consécutives à l'effondrement du cours des actions de la société en bourse.

État actuel de l'affaire : En cours d'examen devant le tribunal arbitral.

2. Circonstances préalables. Chronologie des événements.

2.1. Acquisition des actions de MS.

Entre 2014 et 2017, les Demandeurs ont acquis 76,2 % des actions de MS :

- 9,9 % — par l'intermédiaire de la société Skyrizon (bénéficiaires effectifs : Du Tao et M. Wang Jing) ;
- 50 % — par l'intermédiaire de sociétés holding d'investissement (Du Tao, Li Fengzhou, Zheng Zhinlin, Wang Jing et Cui Changshun) ;
- 9,9 % — par l'intermédiaire de la société Likatron Enterprises Limited (bénéficiaire effectif : Zheng Zhinlin) ;
- 6,2 % — par l'intermédiaire de la société Twinstar Holding S.A. (bénéficiaire effectif : Liu Yanying).

Par ailleurs, Wang Xinyue détenait directement 5 % des actions.

En 2017, les Demandeurs envisageaient de consolider 56 % des actions au sein de Skyrizon, qui devait ensuite être rachetée par la société Beijing Xinwei Technology (ci-après « Xinwei »). L'objectif était d'accéder à la bourse de Shanghai, sur laquelle les actions de Xinwei étaient cotées. Une telle concentration requérait l'autorisation préalable du Comité antimonopole d'Ukraine (AMKU).

2.2. Tentatives d'obtention de l'autorisation de concentration et premières mesures pénales.

Le 9 juin 2017, Skyrizon et MS ont déposé une demande conjointe auprès de l'AMKU pour obtenir l'autorisation de concentration. L'AMKU a refusé d'examiner le dossier au motif de l'absence des pièces requises. De manière identique, une seconde demande déposée le 30 juin 2017 a été rejetée pour des motifs similaires.

Le 30 juin 2017, une nouvelle demande a été soumise à l'AMKU, dont l'examen a également été refusé sur la base de considérations analogues.

Les démarches ultérieures des autorités étatiques ukrainiennes ont visé à faire obstacle à la concentration planifiée, notamment :

- En juillet 2017, le SBU a ouvert des poursuites pénales concernant les faits d'acquisition des actions ;
- En juillet-septembre 2017, selon les affirmations des Demandeurs, des propositions de gestion conjointe de MS leur ont été transmises ;
- Le 7 septembre 2017, le tribunal de district Chevtchenkivsky de Kyiv a prononcé la saisie pénale de 56 % des actions.

Parallèlement, les Demandeurs ont continué à saisir l'AMKU : une troisième demande en date du 29 décembre 2017 a été renvoyée faute de pièces suffisantes, tandis que les demandes des 31 janvier 2018 et 22 février 2018 ont été retirées.

2.3. Accords conclus avec Ukroboronprom et nouvelle saisie judiciaire.

Entre septembre et décembre 2017, les Demandeurs ont mené des négociations avec la partie ukrainienne sur un modèle de gestion conjointe de MS. Le 29 décembre 2017, les parties se sont accordées sur les conditions fondamentales de cette coopération avec la participation du Consortium d'État « Ukroboronprom ».

Le 6 mars 2018, le Président a promulgué un Décret portant mise en application de la décision du RNBO, par laquelle le projet de convention de coopération était formellement validé.

À la veille de l'assemblée générale annuelle (25 avril 2018), Ukroboronprom a exigé l'intégration de ses représentants au Conseil de surveillance. Les Demandeurs s'y sont opposés, en invoquant l'absence d'accord formellement finalisé et l'absence de statut d'actionnaire d'Ukroboronprom.

Dès lors, les pressions de la part de l'Ukraine ont repris avec vigueur :

Le 20 avril 2018, le tribunal Chevtchenkivsky a de nouveau saisi 56 % des actions, interdisant aux établissements dépositaires de délivrer le registre des actionnaires, ce qui a rendu matériellement impossible la tenue de l'assemblée générale ; le 23 avril 2018, une perquisition a été menée dans les locaux de MS.

Le 27 avril 2018, Skyrizon, Xinwei et Ukroboronprom ont conclu un contrat de coopération prévoyant l'attribution à Ukroboronprom de 25 % des actions et un apport de 100 millions USD d'investissements, sous réserve de la levée des saisies judiciaires, de l'autorisation de concentration et de la mise en œuvre du projet industriel à Chongqing.

2.4. Nouvelles tentatives d'autorisation de la concentration en 2019–2020.

D'avril 2018 à juin 2019, les parties ont procédé à la mise au point des documents d'application. Le 19 juin 2019, le train d'accords correspondant a été formellement conclu.

Le 6 juin 2019, Skyrizon, MS et Ukroboronprom ont soumis à l'AMKU une nouvelle demande d'autorisation de concentration, déclarée recevable. Son instruction s'est poursuivie jusqu'en août 2020, ralentie par le défaut de transmission par Ukroboronprom des renseignements sollicités par l'AMKU.

Au cours de cette période, les États-Unis ont commencé à exercer de fortes pressions sur le gouvernement ukrainien pour bloquer la concentration et contraindre à la cession de MS à des sociétés américaines.

Face à l'échec des accords avec Ukroboronprom, les Demandeurs ont fait appel à un nouveau partenaire ukrainien — le groupe DCH. Le 4 août 2020, un contrat a été signé en vertu duquel DCH obtenait le droit d'acquérir 25 % des actions après la levée des saisies et l'approbation de l'AMKU.

Le même jour, la demande précédente soumise à l'AMKU a été retirée et une nouvelle demande conjointe avec DCH a été déposée. De façon similaire, les demandes des 23 septembre 2020 et 22 octobre 2020 ont été laissées sans examen.

La demande déposée le 18 décembre 2020 a été reçue par l'AMKU, mais celui-ci a refusé le 4 février 2021 de délivrer l'autorisation, invoquant l'entrée en vigueur de sanctions à l'encontre des Demandeurs.

2.5. Naissance du différend relatif aux investissements et déclenchement de l'arbitrage.

Le 4 septembre 2020, les Demandeurs ont notifié au ministère de la Justice de l'Ukraine l'existence d'un différend d'investissement assorti d'une proposition de règlement amiable.

Le 5 décembre 2020, les Demandeurs ont formellement déposé leur Requête d'arbitrage.

Ces dates constituent le point de repère chronologique essentiel pour apprécier le durcissement ultérieur des poursuites pénales et des mesures étatiques visant MS.

2.6. Intensification des mesures étatiques après le déclenchement de l'arbitrage.

Dès l'engagement du contentieux arbitral, l'appareil répressif ukrainien s'est intensifié de manière spectaculaire :

- En décembre 2020, ouverture de poursuites pénales au titre de prétendues irrégularités commises lors de la privatisation historique de MS ;
- Le 29 janvier 2021, adoption de sanctions présidentielles contre Wang Jing, Du Tao, Skyrizon et Twinstar ;
- Le 29 janvier 2021, nouvelle saisie ordonnée par le tribunal sur 56 % des actions, assortie d'interdictions bloquant l'exercice des droits corporatifs ;
- Le 31 janvier 2021, le SBU effectue une perquisition sur le lieu où devait se tenir l'assemblée générale des actionnaires pour en empêcher la tenue.

Le 11 mars 2021, le RNBO a adopté une décision (rendue exécutoire par Décret présidentiel du 23 mars 2021) prévoyant le retour de MS dans le giron patrimonial de l'État, comme l'a expressément confirmé le secrétaire du RNBO.

Le 16 mars 2021, le SBU a obtenu un rapport du Service national d'audit d'Ukraine (ci-après « GASU »), affirmant que les biens de MS n'avaient pas été correctement indexés lors de la privatisation, ce qui aurait conduit à une sous-évaluation. Sur le fondement de ce rapport, les actions et actifs de MS ont été qualifiés de pièces à conviction.

2.7. Saisie de 100 % des actions et dépossession forcée ultérieure.

Le 20 mars 2021, le tribunal Chevtchenkivsky a ordonné la saisie de 100 % des actions de MS et les a placées sous la gestion de l'ARMA.

Dans leur ensemble, les mesures indiquées ont substantiellement limité la possibilité des Demandeurs d'exercer les droits sur les actions leur appartenant et constituent une partie du fondement factuel de leurs demandes contre l'Ukraine dans l'arbitrage.

Ultérieurement, sous le régime de la loi martiale, les actions de MS ont fait l'objet d'une expropriation forcée au profit de l'État.

3. Expropriation forcée des actions de MS.

Le 5 novembre 2022, lors d'une réunion de la Stavka du Commandant en chef suprême, a été décidée l'aliénation forcée et le transfert à l'État des actions d'entreprises d'importance stratégique, au nombre desquelles figurait MS.

Le 6 novembre 2022, la Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier a acté l'aliénation forcée des actions de MS. Les actions ont acquis le statut de biens militaires et ont été transférées sous la gestion du ministère de la Défense.

Aux termes des dispositions législatives applicables, à l'issue de la loi martiale, ces actions doivent être restituées à leurs propriétaires ou faire l'objet d'une juste indemnisation financière.

4. Portée et incidence sur le présent dossier.

4.1. L'arbitrage et les poursuites pénales partagent un même noyau factuel.

Le différend arbitral et les enquêtes pénales portent rigoureusement sur le même complexe de faits :

- L'acquisition d'actions de MS par les investisseurs chinois ;
- Les structures de détention capitalistique et l'obligation d'obtenir l'accord de l'AMKU ;
- L'application ultérieure de mesures restrictives et coercitives par l'État ukrainien sur ces actions.

Les autorités judiciaires françaises ont reconstitué de manière distincte l'opération désignée « Project ZOOM ». L'enquête française a analysé en détail la structuration de la transaction à travers des sociétés intermédiaires, le transfert des actions aux investisseurs chinois, les règlements financiers afférents et la question de l'absence d'agrément de l'AMKU.

Les pièces contractuelles initiales de l'opération désignent Wang Jing comme représentant de Skyrizon et consignent expressément la position des parties selon laquelle aucune autorisation de concentration de l'AMKU n'était formellement requise (1).

Ces mêmes actions et ces mêmes constructions de droit des sociétés ont fait l'objet des poursuites pénales ukrainiennes n° 22017000000000272 (ci-après « dossier n° 0272 »).

En 2017–2018, les autorités ukrainiennes ont saisi les actions comptabilisées au nom de Skyrizon, Business House Helena AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, Likatron Enterprises Limited et Wang Xinyue.

Les enquêteurs ukrainiens ont justifié ces saisies en échafaudant la thèse d'une acquisition indirecte par la partie chinoise de plus de 50 % des actions sans l'autorisation obligatoire de l'AMKU (2).

Les saisies limitaient la possibilité de céder les actions et d'exercer les droits y afférents. C'est précisément la limitation des droits sur les actions qui constitue l'un des fondements factuels des demandes arbitrales.

Ainsi, les poursuites pénales se trouvent directement intriquées dans l'objet même de l'arbitrage. Les faits investigués au pénal visent les modalités d'acquisition des actions de MS et les mesures d'éviction prises par l'État.

4.2. Les éléments examinés dans les poursuites pénales ont une incidence déterminante sur la défense de l'Ukraine dans l'arbitrage.

Les enquêtes pénales englobent l'ensemble des éléments suivants :

- L'acquisition et l'ingénierie financière des actions de MS ;
- L'application de la législation sur la protection de la concurrence économique ;
- Les liens corporatifs unissant les protagonistes de l'opération « Project ZOOM » ;
- Le contrôle effectif exercé sur les véhicules sociétaires mobilisés dans la transaction.

Les enquêteurs français explorent activement ces aspects, notamment la chaîne de propriété, les pouvoirs de gestion sur les entités et leurs comptes bancaires, ainsi que les documents sociaux et bancaires saisis à Monaco (3, 4).

Par conséquent, les pièces réunies par l'instruction pénale corroborent directement les faits liés à l'acquisition et à l'architecture de l'investissement. Ces éléments conditionnent l'appréciation des demandes des investisseurs chinois et la légitimité des contre-mesures adoptées par l'Ukraine.

La thèse élaborée au pénal répond donc pleinement à l'intérêt financier et patrimonial de l'Ukraine dans le cadre de sa défense arbitrale.

Cette étroite corrélation a été ouvertement reconnue dès la genèse du litige.

Dès septembre 2020, parmi les moyens de défense opposables par l'Ukraine en arbitrage figurait le grief d'acquisition illégale des actions sans l'accord de l'AMKU (Annexe 1).

En décembre 2021, des sources publiques indiquaient explicitement que la démonstration du caractère illicite de l'acquisition des actions et les conclusions des enquêtes pénales permettraient de renforcer substantiellement la position défensive de l'Ukraine dans l'arbitrage (Annexe 2).

4.3. La réactivation du volet de la privatisation consécutivement au différend arbitral.

Avant le déclenchement de l'arbitrage, le volet relatif à la privatisation et à la fiscalité avait déjà été instruit dans le cadre de la procédure pénale n° 42017080000002509.

Le 26 décembre 2019, cette procédure avait été définitivement classée sans suite au motif de l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction pénale.

Ce classement s'appuyait notamment sur les conclusions d'une expertise judiciaire d'État approfondie. Cette expertise n'avait relevé aucun écart entre le procès-verbal d'évaluation du complexe patrimonial de MS et les registres comptables.

L'expert judiciaire avait en outre formellement souligné qu'il était matériellement impossible de déterminer la valeur de marché telle qu'elle existait en 1994, en raison de l'évolution des doctrines et méthodes d'évaluation économique.

Or, le 4 septembre 2020, les investisseurs chinois ont notifié à l'Ukraine l'existence du différend, puis ont enregistré leur Requête d'arbitrage le 5 décembre 2020.

Dès la survenance de ce différend d'investissement, l'appréciation juridico-pénale de la privatisation a opéré un revirement radical :

Le 29 janvier 2021, l'OGP a annulé l'ordonnance de classement sans suite et a confié la reprise de l'instruction au SBU.

Dès le 16 mars 2021, le SBU a réceptionné un rapport du GASU alléguant de prétendues anomalies dans l'évaluation et l'indexation des actifs lors de la privatisation.

Le 23 mars 2021, l'organisme d'expertise scientifique du SBU a dressé des conclusions qui, sur la base exclusive du rapport du GASU, validaient par simple calcul arithmétique le montant du préjudice théorique allégué.

Ainsi, après l'annulation de l'ordonnance de classement sans suite, en moins de deux mois a été constituée une nouvelle base probatoire du volet de la privatisation – la conclusion du GASU sur les violations lors de l'évaluation des biens et le calcul d'expertise des pertes qui en découle.

Le 9 novembre 2021, la procédure pénale n° 2509 a été jointe au dossier n° 0272, dans lequel étaient déjà instruites les conditions de rachat et de saisie des actions de MS constituant le substrat factuel du contentieux arbitral.

Il est dès lors manifeste qu'un volet d'infraction sous-jacente majeur, préalablement classé sans suite pour absence d'infraction, a été rouvert, réévalué et inclus dans une procédure plus large du SBU à l'égard de MS dès la notification du risque financier international pesant sur l'Ukraine.

Cela confirme le renforcement rétrospectif de la version pénale après la survenance du risque patrimonial de l'Ukraine dans l'arbitrage.

4.4. La procédure pénale française n'est pas autonome par rapport à l'arbitrage.

Grâce à l'Équipe commune d'enquête (ÉCI / JIT), l'Ukraine a obtenu un accès privilégié à des éléments de preuve recueillis sur le territoire d'États tiers.

Le 14 février 2024, les autorités compétentes de la Principauté de Monaco ont autorisé la transmission aux autorités ukrainiennes du produit des perquisitions exécutées sur leur territoire.

Le 22 février 2024, la partie française a remis à la délégation ukrainienne deux clés USB contenant des copies de documents bancaires saisis auprès des établissements Julius Baer et Union Bancaire Privée (UBP), ainsi que l'extraction de supports numériques (5).

Le 18 mars 2024, les autorités françaises ont sollicité de l'Ukraine la communication des pièces relatives à la demande d'arbitrage formulée par les actionnaires chinois de MS. Le ministère de la Justice de l'Ukraine a transmis ces éléments et a expressément validé leur partage avec la France et Monaco.

Simultanément, le ministère de la Justice a engagé des démarches pour obtenir des autorités françaises et monégasques l'autorisation d'utiliser les éléments probatoires remis le 22 février 2024 afin de bâtir la défense juridique de l'Ukraine dans l'arbitrage international.

Le 27 mars 2024, l'OGP a saisi officiellement la partie française pour requérir cette autorisation et l'inviter à solliciter une dispense analogue auprès de Monaco (6).

Ce faisant, l'OGP a expressément souligné que les pièces issues de l'entraide pénale internationale ne pouvaient initialement être exploitées que dans le strict cadre du dossier n° 0272, et que leur versement aux débats de l'arbitrage exigeait l'accord formel et distinct de la France et de Monaco.

Cette démarche prouve sans ambiguïté que l'Ukraine a expressément assigné aux pièces de l'enquête pénale un objectif extra-pénal direct : l'étayage de sa défense dans le contentieux arbitral.

Ainsi, les pièces de la procédure pénale n° 0272 ont été utilisées par l'Ukraine également dans d'autres procédures patrimoniales extra-pénales.

Ainsi, par décision du 18 avril 2024 rendue dans l'affaire n° 991/558/24, la Haute Cour anticorruption d'Ukraine (HACC / VAKS) a constaté que le ministère de la Justice avait obtenu du SBU des pièces issues des poursuites pénales ainsi que l'autorisation de les exploiter aux fins d'introduire devant le HACC une action en confiscation d'actifs au titre des sanctions étatiques (Annexe 3).

Sur le plan international, les poursuites pénales poursuivent également un but patrimonial immédiat pour l'État ukrainien.

Selon les déclarations officielles d'Eurojust, des avoirs d'une valeur approximative de 57 millions d'euros ont été gelés sur le territoire français, fonds dont l'Ukraine poursuit activement la restitution à son profit (Annexe 4).

L'Ukraine tire ainsi un intérêt patrimonial et procédural direct de l'aboutissement de cette coopération judiciaire internationale.

4.5. Conclusions :

L'ensemble des circonstances souverainement constatées établit formellement que :

- (1) L'arbitrage international et les poursuites pénales partagent un socle factuel parfaitement identique quant aux modalités d'acquisition des actions et aux restrictions étatiques subséquentes ;
- (2) La thèse de l'enquête pénale relative aux conditions d'acquisition et à la détention des titres a objectivement une valeur probante pour la défense de l'Ukraine dans l'arbitrage ;
- (3) Consécutivement à l'introduction du différend arbitral, le volet relatif à la privatisation, initialement classé sans suite, a été rouvert, a reçu une nouvelle base probante et a été inclus à la procédure n° 0272 ;
- (4) L'Ukraine a expressément provoqué l'exploitation des pièces recueillies au titre de l'entraide judiciaire pénale pour assurer le succès de sa défense dans l'arbitrage international.

Ainsi, l'Ukraine utilise directement les résultats de l'enquête pénale pour la défense de sa position dans l'arbitrage.

---

(1) T3_PGS_PV110 ; T3_ESS_ES22.

(2) T3_ESS_ES78.

(3) T3_PGS_PV110 ; T3_ESS_ES73.

(4) T3_ESS_ES04 ; T3_PGS_PV112.

(5) T3_PGS_PV048.

(6) T3_PGS_PV061.